

1523396-75.2021.8.26.0266

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL VIEIRA PATARA

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Repte(a)(s):

Justiça Pública

Repto(a)(s):

CLEONICE APARECIDA JARDIM, JOSE APARECIDO PEREIRA QUEIROZ e REGINALDO GROTO

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

JOSE APARECIDO PEREIRA QUEIROZ, REGINALDO GROTO e CLEONICE APARECIDA JARDIM foram denunciados e estão sendo processados como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

3ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, ., Centro - CEP 11740-000, Fone: (13) 3422-1215,

Itanhaém-SP - E-mail: itanhaem3@tjsp.jus.br

Processo nº:

1523396-75.2021.8.26.0266

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Repte(a)(s):

Justiça Pública

Repto(a)(s):

CLEONICE APARECIDA JARDIM, JOSE APARECIDO PEREIRA QUEIROZ e REGINALDO GROTO

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

JOSE APARECIDO PEREIRA QUEIROZ, REGINALDO GROTO e CLEONICE APARECIDA JARDIM foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, porque no dia 08.11.2021, por volta das 18h00min, na Av. Bahia, 10, Jardim Coronel, nesta cidade e comarca de Itanhaém, os agentes supra apontados, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos, tinham em depósito e traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 66 (sessenta e seis) tijolos da droga Cannabis sativa L, popularmente conhecida por maconha, acondicionados em sete pacotes devidamente lacrados, pesando 77,600 kg, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 02.12.2021 (pág. 185).

Os réus foram citados (fls. 260, 263 e 369) e apresentaram respostas escritas à acusação (págs. 209/212, 274/277 e 370/375).

Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, foram realizados os interrogatórios dos réus (págs. 413/415).

O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado aos autos às págs. 269/273.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão inicial, condenando-os nos exatos termos da denúncia.

A defesa de José Aparecido Pereira Queiroz, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso II ou V, do Código de Processo Penal ou, em caso de condenação, a pena deve ser fixada no mínimo legal, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, aplicando-se o redutor no grau máximo e, conseqüentemente, fixando-se regime inicial mais brando para cumprimento de pena e a concessão ao réu da possibilidade de recorrer em liberdade.

A defesa de Cleonice Aparecida Jardim e Reginaldo Groto, no entanto, requereram preliminarmente, o reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade que recai sobre a quebra da cadeia de custódia da prova e, em acolhimento as preliminares, requerem a absolvição dos réus com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal e, caso não seja esse o entendimento, que sejam absolvidos pelo mesmo artigo, inciso VII ou, que a pena seja aplicada no mínimo legal, com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com regime prisional menos gravoso, sendo operada a detração penal para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, que possam recorrer em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

De proêmio, REJEITO o pedido de liberdade provisória feito em audiência pela Defesa do corréu Reginaldo Groto, tendo em vista que ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, conforme demonstrado as págs. 104/107 e a Defesa não trouxe qualquer fato novo que pudesse embasar tal pedido.

Outrossim, REJEITO a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, visto que o pedido já fora indeferido anteriormente pelas razões já expostas (pág. 255, 293 e 385), e não houve recurso interposto no momento adequado, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

E, ainda, quanto a preliminar de nulidade por força de ausência de perícia no local e na enxada, não merecem acolhida, isto porque a apreensão dos entorpecentes é suficiente para comprovar a materialidade do crime, sendo, portanto, desnecessária a perícia no local, bem como na enxada, diante da prova material consistente nos entorpecentes apreendidos. Ademais, a perícia no local foi suprida pela prova testemunhal produzida em Juízo.

Por fim, no que tange a preliminar de nulidade da prova colhida, em que a Defesa alega ter havido quebra na cadeia de custódia, também não merece prosperar, uma vez que a Defesa não trouxe aos autos qualquer prova que demonstre que houve qualquer adulteração no iter probatório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INTEGRIDADE E INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Na hipótese, o Tribunal apontou que o reconhecimento da nulidade na cadeia de custódia demandaria uma incursão aprofundada no exame da

prova “na medida em que pressuporia a oitiva dos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas acima indicadas e seu cotejo com os demais elementos de prova, num juízo que claramente desborda do espectro do “habeas corpus””. 2. Além disso, apontou que “tampouco há como se assentar, ao menos à luz dos documentos trazidos à impetração, que a defesa não tenha tido acesso à integralidade das provas produzidas, tal como fornecidas à polícia federal”. 3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Posto isso, também REJEITO a preliminar aventada.

Ao mérito, pois.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 03/04), pelo boletim de ocorrência (págs. 17/23), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 09/10), pelo laudo de exame químico toxicológico (págs. 269/273), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é inconteste e deve ser atribuída aos acusados.

A testemunha arrolada pela acusação, Gabriel Pereira de Souza, ouvido em Juízo, Policial Militar, disse que foram informados através de uma denúncia anônima de que havia entorpecentes escondidos no bairro Jardim Coronel, e que indivíduos estariam vindo para busca-la. Em diligência, visualizaram, em uma rua sem saída, um veículo que a placa batia com a que receberam pela denúncia, motivo pelo qual realizaram a abordagem e encontraram os réus, os quais estavam realizando o carregamento do veículo. Afirmou que não os conhecia anteriormente aos fatos, e que os acusados eram da cidade de Guarulhos/SP.

A testemunha arrolada pela acusação, Edson Montesino, ouvido em Juízo, Policial Militar, apresentou os mesmos fatos que seu colega de farda, aduzindo que com o réu Reginaldo fora encontrado um mapa em que estava marcado o local de onde estavam os entorpecentes. Informou que indagados, Reginaldo informou que estava realizando o serviço para pagar advogados, enquanto os outros réus foram para ajudá-lo. Afirmou que foram relatados dois veículos, um Onyx, de cor laranja e um Logan, de cor branca, mas encontraram apenas um deles, enquanto o outro fora encontrado em local indicado pelo réu Reginaldo. Asseverou que os entorpecentes foram levados na viatura e não fora realizada perícia de local.

Não há razão suficiente para invalidar os depoimentos dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de depor, só porque ostentam essa qualidade, pois, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que:

"(...) nada impede que policiais ou outros servidores públicos, como quaisquer pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos destes como se, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos de seus próprios servidores. A propósito do valor probante de testemunhos policiais, oportuno trazer

à colação a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: 'VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.' (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293)" (TJSP, Apelação nº 0009710-21.2011.8.26.0176, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, j. 31.03.2016).

Os testemunhos dos Policiais são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, comprovarem a ocorrência do fato típico, e embasarem um decreto condenatório aos réus, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado o depoimento na fase inquisitorial.

O réu, Jose Aparecido Pereira Queiroz, interrogado em Juízo, negou os fatos descrito na denúncia. Disse que é vizinho de Reginaldo e ele havia pedido ajuda para retirar algumas coisas em Praia Grande e, em dado momento, foram à Itanhaém/SP para que ele pudesse ver alguns terrenos. Informou que não estava em posse de nenhum entorpecente.

O réu, Reginaldo Groto, interrogado em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia. Disse que não estavam em posse de nenhum tipo de entorpecente, bem como foram abordados em uma Avenida e não no local informado pelos policiais. Relatou que fora à cidade para retirar alguns pertences do apartamento que estava vendendo em Praia Grande/SP. Esclareceu que não deixaram ligar para o advogado quando chegaram na delegacia e que os policiais pediram dinheiro.

A ré, Cleonice Aparecida Jardim, interrogada em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia. Disse que os policiais estão mentindo, posto que não havia nada dentro do veículo. Relatou que foram à cidade de Itanhaém/SP para olhar um terreno para compra. Negou ter confessado a traficância. Por fim, esclareceu que não deixaram ligar para o advogado quando chegaram na delegacia e que os policiais pediram dinheiro.

Pois bem.

Embora os corréus tenham negado a prática do crime descrito na denúncia, é certo que suas versões restaram isoladas diante da prova colhida em Juízo. Portanto, tem-se que a responsabilidade penal dos réus é nítida, mormente pelas provas colhidas, em especial pela prisão em flagrante e o auto de exibição e apreensão, somados aos depoimentos, tornando-se prova idônea da prática delitiva.

Necessário destacar, ainda, que o tráfico de drogas é praticado às ocultas, logo, para se prolatar decisão condenatória não há necessidade de uma sequência de provas plenas e fartas, pois tal situação não se coaduna com a realidade fática.

A decisão condenatória deve se basear em um quadro suficiente de elementos de convicção, que seja harmônico e convergente para configurar a conduta dos réus, o que de fato ocorre no presente caso.

Ainda que assim não fosse, é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de

certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.

Nem se diga que a existência apenas de indícios impossibilite um decreto condenatório, pois contrariaria doutrina e jurisprudência majoritárias:

"embora não leve à certeza, a jurisprudência tem admitido a condenação quando a prova indiciária for veemente ou então quando várias pequenas circunstâncias sejam, concordes até em detalhes. Um único indício pode levar à condenação, desde que veemente. Por indício veemente entende-se aquele que, dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar todas as hipóteses favoráveis ao acusado. (...) Às vezes uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e concatenados, igualmente podem dar a certeza exigida para a condenação. (...) Em tal hipótese não encontramos um indício que possa ser classificado como veemente, porém a sucessão e a coerência indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante" (Da Prova no Processo Penal - José Q. T. de Camargo Aranha).

"A prova se faz não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções, que devem ser analisados como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os indícios, quando não contrariados por contra indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo e culpa do acusado e sua condenação." (TACRIM-SP - AC - Rel. Marrey Neto - JTACRIM 7/105).

Como se vê, ficou clara a prática de tráfico ilícito de entorpecentes por parte dos réus, inexistindo nos autos qualquer fato que venha ilidir sua responsabilidade penal.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Devem-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. Al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Nesta toada, o conjunto probatório delineado nos autos é mais do que suficiente para empregar o decreto condenatório em desfavor dos réus.

Passo a dosar a pena.

RÉU JOSE APARECIDO PEREIRA QUEIROZ

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (págs. 91/94) observo que o réu possui maus antecedentes, desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Anote-se que a presença de maus antecedentes impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.".

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Segundo o mesmo jurista acima citado, inclusive na mesma obra, "na norma do §4º, para que se possa aplicar a diminuição de pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter maus antecedentes".

Desta forma, o réu tendo maus antecedentes impossível à concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força de expressa proibição legal, e por ser a pena superior a 04 anos. Assim como, em relação à concessão do "sursis" processual.

Dito isso, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, único adequado e suficiente para reprovar sua conduta que afeta significativamente a ordem social, tendo em vista o incurso no artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a redação pela lei 11.464/07, os quais justificam a imposição do regime inicial mais severo.

RÉU REGINALDO GROTO

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (págs.

99/101) observo que o réu não possui maus antecedentes, todavia, analisando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas, que é preponderante sobre o artigo 59 do Código Penal, verifico que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, constituem fundamento apto a ensejar o aumento da pena-base, neste sentido, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. NATUREZA NOCIVA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DA DROGA NÃO EXPRESSIVA. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. [...] (HC 366112 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016; grifei).

Desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes atenuantes e agravantes, deste modo mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ademais, anote-se que a quantidade de drogas apreendidas também impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda."

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Todavia, a grande quantidade de droga envolvida também é indicativo de que o acusado efetivamente se dedicava a atividade criminosa, integrando organização criminosa, posto que é insustentável que um traficante iniciante tenha condições financeiras (lucro próprio do tráfico), para adquirir, fracionar e embalar sozinho, a quantidade de entorpecente dos autos, concluindo-se que, ou recebeu as drogas de

pessoa hierarquicamente superior na organização criminosa, ou a muito tempo vem comercializando as drogas, a ponto de ter dinheiro o suficiente para adquirir a grande quantidade apreendida. Tornando prova apta a indicar que este seria o seu meio de sustento, caracterizando sua dedicação à atividade criminosa.

Desta forma, impossível a concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força de expressa proibição legal, e por ser a pena superior a 04 anos. Assim como, em relação à concessão do "sursis" processual.

Dito isso, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, único adequado e suficiente para reprovar sua conduta que afeta significativamente a ordem social, tendo em vista o incurso no artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a redação pela lei 11.464/07, os quais justificam a imposição do regime inicial mais severo.

RÉ CLEONICE APARECIDA JARDIM

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (pág. 97) observo que o réu não possui maus antecedentes, todavia, analisando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas, que é preponderante sobre o artigo 59 do Código Penal, verifico que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, constituem fundamento apto a ensejar o aumento da pena-base, neste sentido, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. NATUREZA NOCIVA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DA DROGA NÃO EXPRESSIVA. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. [...]" (HC 366112 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016; grifei).

Desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes atenuantes e agravantes, deste modo mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ademais, anote-se que a quantidade de drogas apreendidas também impede a aplicação

da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.".

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Todavia, a grande quantidade de droga envolvida também é indicativo de que o acusado efetivamente se dedicava a atividade criminosa, integrando organização criminosa, posto que é insustentável que um traficante iniciante tenha condições financeiras (lucro próprio do tráfico), para adquirir, fracionar e embalar sozinho, a quantidade de entorpecente dos autos, concluindo-se que, ou recebeu as drogas de pessoa hierarquicamente superior na organização criminosa, ou a muito tempo vem comercializando as drogas, a ponto de ter dinheiro o suficiente para adquirir a grande quantidade apreendida. Tornando prova apta a indicar que este seria o seu meio de sustento, caracterizando sua dedicação à atividade criminosa.

Desta forma, impossível à concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força de expressa proibição legal, e por ser a pena superior a 04 anos. Assim como, em relação à concessão do "sursis" processual.

Dito isso, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, único adequado e suficiente para reprovar sua conduta que afeta significativamente a ordem social, tendo em vista o incurso no artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a redação pela lei 11.464/07, os quais justificam a imposição do regime inicial mais severo.

Posto isto:

CONDENO o réu JOSE APARECIDO PEREIRA QUEIROZ qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal.

CONDENO o réu REGINALDO GROTO qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal.

CONDENO a ré CLEONICE APARECIDA JARDIM qualificada nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram, não podendo recorrer em liberdade, pois ainda presentes os requisitos da custódia cautelar. No entanto, para a ré, fora concedida a liberdade provisória, conforme alvará de soltura de págs. 117/119, motivo pelo qual poderá recorrer em liberdade.

Também, após o trânsito em julgado, oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens eventualmente apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Oportunamente, intinem-se os réus para efetuarem o pagamento da multa.

Condeno-os, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Arbitro os honorários dos defensores nomeados, se o caso, no valor máximo da tabela vigente, expeça-se o necessário.

P.I.C., arquivando-se, oportunamente.

Itanhaém, 30 de novembro de 2022.

RAFAEL VIEIRA PATARA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA